

1500270-22.2019.8.26.0280

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... com alguém não afasta por si a ocorrência do crime de tráfico de drogas, mas trata-se de circunstância que pode levantar dúvidas sobre a ocorrência daquele delito.

Neste ponto, consigno que, do que consta dos autos, a situação acima relatada, ao passar pelo juízo sumário da autoridade policial, não pareceu, para aquela, configurar o delito de tráfico de drogas, razão pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri-SP - cep 11760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500270-22.2019.8.26.0280 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-22.2019.8.26.0280

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3074076/2019 - DEL.POL.PERUIBE,
6273466 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Vistos.

ADRIANO DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigos 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 , porque, segundo consta na denúncia, no dia 13 de julho de 2019, por volta das 03 horas, na Rua Benedito Muniz, 495, Centro, Itariri-SP, o réu transportava, para o fornecimento e consumo de terceiros, 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, com peso de 23.8g (vinte e três gramas e oitenta decigramas), drogas que determinam dependência física ou psíquica, como faz certo o auto de constatação definitivo de fls.37/39, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente citado/notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 73/77).

A denúncia foi recebida (fls. 81/84).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado,

mediante sistema de filmagem e gravação de áudio.

Em alegações finais, após análise da prova produzida nos autos, o Ministério Público requereu a da ação e a condenação do réu pelo crime de tráfico. A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão punitiva deve ser julgada improcedente, já que, conforme se verá em sequência, a conduta praticada pelo réu se enquadra, formalmente, na figura descrita no art. 28 da Lei de Drogas, o qual é inconstitucional.

Eis a síntese da prova oral colhida em contraditório.

A testemunha José Siqueira disse que no dia dos fatos estava de patrulhamento pela cidade e na rua encontrou uma moto na contramão. Deram sinal de parada e o motoqueiro se esquivou da viatura. A polícia foi atrás e o condutor da moto perdeu o equilíbrio. A polícia abordou e na cintura de Adriano, se não falha a memória, fora, encontrados pinos. Adriano disse que era usuário. O garupa falou que tinha emprestado a moto para Adriano. A moto era do garupa, se a testemunha não se engana. Não se recorda de ter encontrado dinheiro.

A testemunha Marcelo da Silva Santos disse que estavam em patrulhamento pela área central de Itariri quando na rua Benedito Muniz viram uma moto na contramão com dois ocupantes. Tentaram abordar mas eles evadiram-se na motocicleta. Foram acompanhando e conseguiram alcançar. Em revista pessoal, foi encontrada nas vestes do réu uma bolsa com 39 pinos de substância aparentando ser cocaína. O réu falou que seria para uso próprio e que a motocicleta era do garupa, que a emprestou ao réu. O garupa parecia sob efeito de drogas. Tinha pouco dinheiro com o réu. Não se lembra a quantia mas era pouco. Foi o Cabo Siqueira quem fez a abordagem. O depoente estava ao lado durante a abordagem.

A testemunha Jorge Eneas Alves dos Santos disse que tem amizade com Adriano há uns três anos. Ele é usuário de drogas. Usa cocaína. Ele trabalha com o pai dele, de servente de pedreiro. Nunca viu Adriano vendendo drogas. No dia que Adriano foi preso a testemunha não foi com ele comprar droga. A testemunha não sabia se Adriano estava sob efeito de drogas no dia dos fatos. Indagado se o réu já fez tratamento para o uso de drogas, disse que pelo que sabe, não. Sabe que ele é usuário porque tempos atrás viu ele na estrada com um "negócio desse aí". Era perto da casa dele. O réu estava perto da casa dele usando. Viu isso aí uma vez só. Faz um ano e pouco que viu isso. Antes nunca viu, porque não anda com o réu direto.

Interrogado, o réu disse que parte dos fatos são verdadeiros. Foi comprar em Peruíbe. Era usuário de cocaína. Comprou 40 pinos, por 200 reais, se não se engana. Usou um pino e veio embora para Itariri, indo para um bar beber. Foi quando encontrou com Jorge, uma 14:00. O réu pediu carona para Jorge, mas como Jorge estava mais bêbado, o réu foi dirigindo a moto. Foi quando encontrou a polícia. Não estava com mochila com pó. Estava no bolso dele. E não tinha dinheiro. O réu não vende drogas. O depoente mora em Itariri, no bairro da Igrejinha. O réu voltou de Peruíbe de ônibus. Indagado se não achou melhor passar em casa para deixar os 39 pinos em vez de ir com eles para o bar, disse que era isso que fazia de costume: comprar e ir para casa, mas nesse dia o réu parou para beber e ficou embriagado, sob efeito de drogas e bebidas. Ainda assim foi o depoente que dirigiu a moto, porque estava melhor que o carona, que estava muito ruim. A droga que comprou usaria durante a semana. Recebia na sexta e usaria durante a semana. Usava de 5 a 6 pinos por dia. Tem dia que usa mais.

Somado a prova oral acima, tem-se ainda o termo circunstanciado de ocorrência de fls. 4/6, o auto de exibição e apreensão de fls. 8/9 e o laudo toxicológico definitivo de fls. 37/39.

Por toda a prova e elementos de informação mencionados, é possível concluir que o réu transportava, na moto que conduzia, 39 porções de cocaína.

Resta, no entanto, a dúvida sobre o fim que o réu pretendia dar para a droga que transportava.

O Ministério Público, na denuncia oferecida e em alegações finais, sustentou que as drogas se destinavam ao comércio ilícito.

A Defesa técnica e a autodefesa sustentaram que as drogas destinavam-se ao consumo

pessoal do acusado.

De saída, convém dizer a quantidade de droga apreendida com o réu, qual seja, 39 porções de cocaína, não se presta a, por si só, comprovar a finalidade da substância intorpecente, já que não é grande demais para não tornar crível que alguém disponha dela para consumo em curto ou médio período de tempo, nem tão pequena para afastar com certeza a intenção de venda ilícita.

Assim, há que se observar se os demais elementos dos autos são suficientes para afastar a possibilidade de aquelas drogas se destinassem ao consumo pessoal.

Isso porque o ônus da prova é da acusação, incumbindo a esta demonstrar, para além de uma dúvida razoável, a ocorrência do delito imputado.

Nesse sentido, cito precedente do STF:

SENTENÇA ENVERGADURA. Ante o fato de o Juízo ter contato direto com as partes envolvidas no processo-crime, o pronunciamento decisório há de merecer atenção maior. PROCESSO-CRIME PROVA. Cabe ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio da não culpabilidade a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de entorpecentes em razão de o acusado não haver feito prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de amigos que se cotizaram para a aquisição. (HC 107448, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 03-10-2013 PUBLIC 04-10-2013)

Pois bem.

Os policiais ouvidos em Juízo não disseram que receberam denúncias anônimas dando notícia de que o réu, ou pessoa semelhante a ele, estaria traficando na região onde ele foi abordado. A abordagem se deu porque o réu conduzia uma moto na contramão da via de direção.

Nos elementos de informação colhidos no curso das investigações preliminares, com destaque para o Boletim de Ocorrência de fls. 2/3, para o Termo Circunstanciado de fls. 4/6 e para o termo de exibição e apreensão de fls. 8/9 não consta que com o acusado foi encontrada nenhuma quantia em dinheiro.

A testemunha José Siqueira, que foi o responsável pela abordagem do réu, disse que não se recorda de haver localizado dinheiro com o acusado.

Já a testemunha Marcelo disse em juízo que encontrou um pouco dinheiro com o réu, mas que não se lembra a quantia.

O depoimento de Marcelo, neste ponto, confronta com todas as outras provas dos autos, inclusive com o depoimento de José Siqueira, que foi quem realizou a abordagem no réu.

Assim, não é prova segura de que o réu foi encontrado com dinheiro quando ocorreu a abordagem.

Não comprovado que o réu trazia consigo dinheiro, é de se estranhar que alguém que estaria traficando drogas não tivesse consigo nenhum valor em dinheiro, seja resultante de alguma venda (caso já tivesse iniciado a traficância naquele momento) seja para dar eventual troco (caso ainda estivesse se dirigindo para onde comercializaria as drogas).

Por certo a ausência de dinheiro encontrado com alguém não afasta por si a ocorrência do crime de tráfico de drogas, mas trata-se de circunstância que pode levantar dúvidas sobre a ocorrência daquele delito.

Neste ponto, consigno que, do que consta dos autos, a situação acima relatada, ao passar pelo juízo sumário da autoridade policial, não pareceu, para aquela, configurar o delito de tráfico de drogas, razão pela qual foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência e termo de compromisso (fls. 4/6 e 7).

Ademais, não há prova de efetiva mercancia da droga o que, apesar de não ser essencial ao tipo do tráfico, conferiria segurança para afastar a finalidade do exclusivo uso.

Não bastasse isso, a testemunha Jorge Enéas, em Juízo e em investigações preliminares (fls. 5), informou ter conhecimento de que o réu é usuário de drogas.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é tipo incongruente, ou seja, o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige o elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta.

Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio (REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

Apenas quando afastada essa possibilidade, com segurança, será possível a condenação no tipo do tráfico de drogas, esse sim congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, não se exigindo o elemento subjetivo. Na espécie, em razão dos fatos acima expostos, verifico que remanesce dúvida razoável acerca da destinação que o acusado pretendia dar à droga, não sendo possível afastar com certeza a finalidade de consumo próprio.

Em que pese a gravidade dos fatos imputados, isso não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil.

Nisso consiste o mandamento de otimização contido no princípio do in dubio pro reo. Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Assim ensina LUGI FERRAJOLI, ao concluir que "A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune" (Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Destarte, de rigor a conclusão de que o réu incorreu, em verdade, na figura prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Seria o caso de se operar a desclassificação, contudo o referido dispositivo é inconstitucional.

Neste ponto, de início convém dizer que no curso do julgamento RE 635.659, alguns ministros do STF já se manifestaram pela inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei Antidrogas.

Filho-me ao entendimento da Colenda 6ª Câmara Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em Acórdão da lavra do Desembargador JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES, considerou-o inconstitucional.

Confira-se:

O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. (TJSP Apelação Criminal nº 01113563.3/0-0000-000, 6ª Câmara Dir. Criminal, j. 31/03/2008). Transformar aquele que tem a droga apenas e tão-somente para uso próprio em agente causador de perigo à saúde pública implica em frontal violação do princípio da ofensividade, dogma garantista previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.

Isso porque, precipuamente, a conduta do agente que porta drogas para seu consumo invade tão somente a sua esfera pessoal.

Portanto, conclui-se, nesta perspectiva, procedendo-se à aferição da periculosidade ou ofensividade da conduta e seu desvalor social, que há ausência de qualquer lesividade desta conduta de consumo de entorpecentes, já que ela não constitui fato penalmente relevante, porque, atingindo a esfera meramente pessoal do próprio consumidor, não vulnera seriamente a ordem jurídica.

Além disso, a criminalização do porte para uso próprio também viola o princípio constitucional da igualdade, pois há flagrante "distinção de tratamento penal (drogas ilícitas) e não-penal (drogas lícitas) para usuários de diferentes substâncias, tendo ambas potencialidade de determinar dependência física e psíquica" (Salo de Carvalho, A política criminal de drogas no Brasil. Estudo criminológico e dogmático, Editora Lumen Juris, RJ, 2007, p. 253).

Para se consolidar como um adequado instrumento de tutela aos bens jurídicos mais relevantes para o sistema, promovendo efetivamente a prevenção delitiva geral e especial, afastando-se da ideia de um direito penal simbólico, o direito penal deve

intervir nas relações sociais apenas quando determinada conduta atinja o bem jurídico de modo intolerável, intervenção esta que deve cumprir sua finalidade, qual seja, proteger o bem jurídico supostamente lesionado.

E, no caso do Art. 28 da Lei 11.343/06, não se vislumbra qualquer proteção ao bem jurídico tutelado (saúde pública) com a criminalização da conduta lá tipificada.

Outrossim, não se vislumbra, conforme já explanado anteriormente, efetiva lesividade da conduta.

Destaco a propósito o voto do Desembargador Nereu José Giacomolli, que ainda ao tempo do art. 16 da Lei 6368/76, bem enfocou a questão:

"O princípio da ofensividade ao bem jurídico, como afirma Luiz Flávio Gomes (Princípio da Ofensividade no Direito Penal, p. 25), há de ser instrumentalizado e tornado efetivo, sob pena de se ter um discurso liberal e uma aplicação autoritária do Direito Penal. Como bem ensina Carbonell Mateu (Derecho Penal: Concepto y Principios Constitucionales, 1999, p. 215-218), o princípio da ofensividade ou lesividade exige que não haja crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, dentro de um critério valorativo que a norma comporta. Mais, num Estado Social e Democrático de Direito, a intervenção punitiva somente se justifica nas condutas transcendentais aos demais que atinjam as esferas de liberdade alheias, sendo contrário ao princípio da ofensividade o castigo de uma conduta imoral, antiética ou antiestética que não invada a liberdade alheia. Ainda, este princípio descansa na consideração do crime como um ato desvalorado, isto é, contrário à norma de valoração" (TJRS RJTJRGs 240/74 Rec. 70013554571 j. 18.05.2006 RJTJRGs 257/197 e Ap. 70008849051 j. 26.08.2004).

Com efeito, falta lesividade ao tipo penal e sem ela não atua o Direito Penal, pois, na lúcida observação de Claus Roxin, "o legislador, mandatário do povo, tem sua tarefa limitada à proteção do indivíduo dos ataques dos outros e a assegurar uma vida mais livre possível e de maior bem-estar possível, e nada tem a ver com tal tarefa o tutelar moralmente cidadãos adultos contra sua vontade" (Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. Trad. cast. Barcelona, 1989, p. 22)" (TJSP Ap. Rel. Dante Busana JTJ 168/321).

No mais, o art. 28 da Lei de Tóxicos fere o princípio da alteridade, o qual impede a incriminação de conduta que prejudica somente ao agente, ou seja, proíbe a incriminação de ações internas e que só digam respeito ao próprio indivíduo.

Neste sentido, se as ações do indivíduo limitam-se apenas ao seu interior, não transcendendo ao ambiente externo, e por consequência não ferindo, prejudicando ou lesando interesses de outrem, impossível a aplicação do "jus puniendi" (direito de punir pelo Estado).

Justamente por isso, o ordenamento jurídico pátrio vigente não pune a conduta de tentativa de suicídio, por exemplo.

E, neste viés, não há razão de se criminalizar a conduta de porte de drogas para consumo, a qual só prejudica aquele que as utiliza, não se justificando uma intervenção repressiva do Estado.

Na discussão em andamento no Supremo, o Ministro Edson Fachin asseverou:

A interpretação do Direito Penal à luz da Carta da República tem sentido a partir de duas premissas básicas: a diferenciação entre penas e medidas de segurança, e a exigência de expressa previsão constitucional, para justificar a limitação de direitos fundamentais. A primeira premissa indica que, em situações excepcionabilíssimas, é possível atribuir a qualidade de perigo a determinada pessoa. Por isso, exceto nas situações em que o desenvolvimento bio-psico-social afaste a culpabilidade, a separação entre penas e medidas de segurança jamais autorizaria fazer recair sobre a pessoa do agente o juízo de condenações. Já neste ponto é possível antever que a incriminação da drogadição situa-se na tênue delimitação entre o Direito Penal do autor e o do fato. Com efeito, a posse para uso pessoal, embora tipifique a ação, incide sobre conduta que, não raro, é condição essencial da pessoa, e a vetor constitucional que não autoriza a penalização da personalidade. No que tange às limitações dos direitos fundamentais, é preciso que eventual restrição encontre fundamentação constitucional. Nessa diretriz, alberga-se o princípio da tipicidade, a exigir reserva de lei para normas penais.

Considerando que a tipicidade decorre da teoria sobre os direitos fundamentais, ao legislador não compete apenas observar a reserva de lei para tipificar determinada conduta, como também deve demonstrar que pela incriminação outro direito fundamental será protegido. A doutrina costuma indicar que a sede do princípio da ofensividade como parâmetro de controle de constitucionalidade reside no art. 98, I, da Constituição da República. Embora a referência tópica possa constar desse dispositivo, o conteúdo do princípio decorre, de um lado, da opção constitucional e legal por um Direito Penal orientado por fatos; e, de outro, da impossibilidade de se criminalizar condutas que não atinjam um fundamento constitucionalmente assegurado. Nesse sentido, é correto afirmar que o princípio da ofensividade tem assento constitucional e serve de parâmetro para o controle da atividade do Legislativo. Esse controle não incide, entretanto, indistintamente sobre todas as normas penais, nem sobre os objetivos e motivações invocados para edição da norma, pois, em tais circunstâncias, seria preciso recorrer-se a argumentos consequencialistas, para afastar a prerrogativa de avaliação feita pelo Legislativo. O princípio da ofensividade permite, de fato, a limitação do próprio direito, mas não autoriza que se oponham argumentos utilitários à validade normativa. Essa tarefa tem ainda maior importância se o reconhecimento da extensão dos bens jurídicos e da consequente proteção estatal for medida em relação à eventual restrição da liberdade. Nesse sentido, caberia à teoria do bem jurídico identificar quais bens podem justificar a restrição à liberdade. Não se trata, contudo, de afastar a priori qualquer pretensão de permitir ao Estado perseguir fins morais. Ao contrário, inexiste um princípio que delimite a esse ponto a atividade estatal regulatória. É preciso registrar, neste particular, que a possibilidade de se buscar fins morais não é descontextualizada: apenas em sociedades em que haja o respeito à autonomia dos cidadãos, garantindo-se-lhes um amplo espectro de opções valorosas (RAZ, Joseph. *The Morality of Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1986), é que seria possível falar em uma larga margem de avaliação para estabelecer fins morais. O ponto de partida para se delimitar o campo de restrição à autonomia parece estar no princípio da ofensividade: somente havendo dano efetivo, porquanto haveria, por conseguinte, uma interferência na autonomia das outras pessoas, é que se pode legitimar a coerção. A sanção penal é, assim, tão-só uma das formas de se proteger os bens jurídicos. Consubstanciando a mais grave restrição na autonomia dos cidadãos, cumpre, portanto, avaliar se ela é adequadamente posta. E é aqui que tem assento a proporcionalidade. Especificamente em relação à coerção penal, poder-se-ia apontar, na linha do que indica Claus Roxin, serem ilegítimas as incriminações de: motivações ideológicas; autolesão; tabus; fins extrapenais; e abstrações incapazes de constituir bens jurídicos (ROXIN, Claus. *Es la protección de los bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?* In: *La teoría del bien jurídico. Fundamentos de legitimación del derecho penal o juego de laboratorios dogmáticos?* Roland Hefendehl (ed.). Barcelona: Marcial Pons, 2007). Essas considerações parecem indicar que, em vista da ofensa a um bem individual, não se pode dar ensejo à criminalização. Esse norte tem sentido especialmente para o adicto, usuário dependente de droga; impende ajudar o usuário que queira se livrar do poder criminoso da dependência. Frise-se, relativamente a esta inferência, que não se visa inviabilizar a atividade regulatória do Estado, nem mesmo a de imposição de sanções, mas a afastar que a regulação seja feita por meio da coerção penal como primeiro antídoto.

Em seu voto, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim ponderou: Na valoração da importância de determinado interesse coletivo como justificativa de tutela penal há de se exigir a demonstração do dano potencial associado à conduta objeto de incriminação. Em outras palavras, há que se verificar em que medida os riscos a que sujeitos os interesses coletivos podem justificar a conversão destes em objeto de proteção pelo direito penal. Conforme observa PUIG, o Estado Social não pode desconhecer, [na definição de crimes de perigo abstrato], a significação que, por si mesma, implica a extensão social de um determinado interesse e tampouco há de prescindir da exigência de um mínimo de repercussão do interesse coletivo em relação a cada indivíduo. Acredita o autor ser essa a via

adequada se se pretende evitar a hipertrofia do direito penal (PUIG, Santiago Mir, "Concepto de Bien Jurídico-Penal como Limite del Ius Puniedi", Estudos de Direito Penal, Processual e Criminologia em Homenagem ao Prof. Dr. Kurt Maldlener, coordenadores Adhemar Ferreira Maciel et alli. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciário, 2014). E exemplifica justamente com o direito à saúde pública. Não cabe negar, afirma o autor, que a saúde pública é um interesse coletivo que afeta cada indivíduo, mas há que se exigir um determinado grau de lesividade individual para que se possa justificar a intervenção do direito penal. Até agora não se tem afirmado, por exemplo, que o álcool e o tabaco afetam suficientemente a saúde pública a ponto de legitimar a criminalização de sua venda e consumo. Em relação ao tabaco, observa que a proteção da ordem pública coletiva tem sido alcançada com o incremento da proibição de seu consumo em lugares públicos, porém por meio de medidas administrativas. O mesmo raciocínio, ainda segundo PUIG, aplica-se em relação às drogas. Sustenta ser preciso diferenciar as drogas quanto a seus distintos efeitos em relação a cada indivíduo. Além disso, há que se ter em conta que a lesividade individual vem, neste caso, acompanhada do consentimento da vítima. Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas art. 4º da Lei 11.343/06 é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas. Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade. Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social. A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal. Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal. Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional.

Neste sentido, resta claro, inclusive, que o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos viola, não só o princípio da alteridade, considerando-se também que sequer ostenta aptidão para proteger os bens jurídicos declarados como tutelados, quais sejam, a saúde e segurança pública, mas também viola o direito à privacidade e intimidade, os quais devem ensejar ações negativas de abstenção do Estado, nos termos da Carta Magna.

Assim, de rigor a declaração, incidental, da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas.

Disso decorre que a solução para o presente feito é a absolvição do réu da imputação de ter incorrido no art. 33, caput da Lei de Drogas, já que a inconstitucionalidade retira o art. 28 da Lei de Drogas do ordenamento jurídico, de modo que não há para o que se desclassificar a imputação inicial.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA e absolvo o réu ADRIANO SILVA da imputação de ter incorrido no art. 33, caput da Lei de Drogas, com fulcro na art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos expedindo-se o necessário, nos termos do que preconizam as Normas da Corregedoria.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Itariri, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA